

1501094-72.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2280513/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 14617179 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 13635/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501094-72.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501094-72.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2280513/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 14617179 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 13635/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2280513 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 13635/20/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 11 de novembro de 2.020, por volta das 10h40, na Alameda Saturno, quadra 03, Vila Bechelli, nesta cidade, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 115,64 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 120), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 132/133.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 19 de março de 2.021 (fls. 134/137).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 154 e 213 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 216/220 e 216/220).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 164/190 e 225/251, alegando que: 1)- a confissão informal é nula; 2)- as provas são frágeis; 3)- os depoimentos policiais não são suficientes para a condenação; 4)- não foram abordadas ou qualificadas as demais pessoas que estavam no local; 5)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 14/15 (um telefone celular; R\$ 78,00; e 92 porções de substância análoga a maconha) e pelo laudo pericial de fls. 64/67 (noventa e duas porções de maconha com peso de 115,64 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Wellington Camargo da Silva, policial militar, afirmou ter recebido "denúncia" por meio do telefone da base da polícia situada na Avenida Pinheiro Machado. Informava-se que um indivíduo de bermuda, boné preto, camisa branca e rosto tatuado praticava o tráfico na Alameda Saturno, debaixo de uma árvore grande. Dirigiu-se ao local e deparou-se com o réu. Ele tinha as características informadas. Em revista pessoal, foram localizadas porções de maconha embaladas em plástico "zipado", prontas para venda, na bermuda dele. A informação inicial também dava conta de que, num terreno ao lado, haveria mais droga. Os policiais rumaram até o lugar em questão e acharam uma sacola plástica contendo mais algumas porções de entorpecentes. No total, foram apreendidas noventa e duas porções de maconha prontas para a venda. Em poder do acusado, havia setenta e oito reais em dinheiro. Não o conhecia dos meios policiais. Ele confessou que praticava o tráfico. As porções de entorpecente, tanto as encontradas com o réu como no terreno, estavam embaladas da mesma forma, ou seja, plástico lacrado ou "zipado". O acusado ainda disse que o dinheiro era proveniente de vendas de drogas. A testemunha Dário Jose Antunes Goularte, também policial militar, disse ter recebido uma denúncia na base noroeste, segundo a qual um indivíduo de bermuda, boné preto, camiseta clara e com tatuagem no rosto estaria praticando o tráfico na Alameda Saturno, na quadra 03. Deslocou-se ao local informado e avistou o réu embaixo de uma árvore. Ele tinha as características informadas. Em seu poder, foram localizados dezesseis invólucros de maconha e setenta e oito reais em dinheiro. Indagado, o acusado confessou a propriedade da droga. O parceiro policial foi até o terreno ao lado, pois a denúncia informava que ali havia entorpecente guardado, e encontrou uma sacola ao lado do muro, perto do réu, contendo droga. Ele disse que estava desempregado e admitiu que vendia entorpecente. Nunca tinha abordado o réu anteriormente, mas seu parceiro já.

Interrogado em juízo, o réu declarou que estava no local da abordagem em razão de sua namorada residir naquela rua. Ela lhe telefonou e pediu para que fosse até sua casa. Estava do outro lado da rua com dois colegas. Foram abordados pela polícia; porém, seus dois colegas foram liberados. Os policiais mandaram que se levantasse e virasse de costas, dizendo que era denúncia. Não tinha droga consigo. Somente tinha seu celular. Não sabe por que os policiais assim agiram. A moça com quem estava sumiu. Estava na companhia de dois rapazes. Um deles se chama Gabriel. Os dois estão "na rua", na casa deles. Um deles sofreu acidente de moto. Os dois colegas foram também revistados. Não havia ninguém chamado Pedro. É possível que o outro colega tenha o nome de Pedro. São colegas "de conversa". Não viu se os policiais encontraram drogas, nem mesmo no terreno. No trajeto para a delegacia, não lhe foi exibido entorpecente. Também não viu droga na delegacia. Não trazia dinheiro consigo. Os dois rapazes não foram levados para a delegacia.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da

denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

É certo que o réu, quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais o acusado foi flagrado na posse de 16 porções de maconha e R\$ 78,00, bem como foi encontrado, nas proximidades, uma sacola contendo outras porções da mesma droga e embaladas de forma idêntica, todas próprias para venda no varejo.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Por outro lado, o discurso do réu é inverossímil.

Se ele estava no local porque sua namorada ali residia e lhe telefonou para que fosse até a casa dela, fácil seria provar o alegado.

Bastaria que a namorada fosse arrolada como testemunha, para que ela comparecesse em juízo e confirmasse morar na região e ter telefonado para Wellington.

Outrossim, se fosse verdade que o acusado estivesse simplesmente na companhia de outros dois "colegas de conversa", do outro lado da rua, sem nada de ilícito portar, igualmente a prova da afirmação poderia ter sido produzida de maneira simples.

Bastaria, novamente, que ao menos um dos colegas fosse arrolado como testemunha.

Ainda, a declaração do acusado, no sentido de que sequer tinha dinheiro consigo, é inverossímil.

Com efeito, não há como acreditar que policiais militares, cujos vencimentos não são dos mais elevados, iriam se dispor a tirar de seus bolsos a quantia de R\$ 78,00, a fim de incriminar um indivíduo que sequer conheciam e que já trazia consigo e guardava nada menos do que setenta e oito porções de maconha.

Prosseguindo, não há dúvida de que o réu estava praticando tráfico, pois foi flagrado na posse de quantidade razoável de entorpecente, bem como de dinheiro, e não deu qualquer explicação plausível a partir da qual se pudesse inferir que o entorpecente tinha destinação outra que não a entrega a terceiros.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas, define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde e a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Enfim, ainda que não se leve em conta a confissão informal, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria restaram bem evidenciados.

Logo, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, impõe-se a condenação pelo crime de tráfico.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes (fls. 32/36).

Deste modo, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida, considerando que a apreensão versou sobre maconha, assim como a de dinheiro, não eram das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa. Outrossim, nenhum outro elemento de prova permite concluir que ele integrava organização criminosa ou era traficante contumaz.

Cabível, pois, o privilégio.

Nada obstante, a redução da pena não pode se dar no patamar máximo de dois terços, haja vista que a apreensão recaiu sobre quantidade de maconha que, embora não das mais elevadas, era ao menos razoável.

Afigura-se justo, pois, deferir a diminuição de pena no patamar de metade, resultando em dois anos e seis meses de reclusão, mais duzentos e cinquenta dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequena quantidade de dinheiro e apenas razoável de droga), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro não serem das mais elevadas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base

fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins.(TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Wellington dos Santos Rodrigues como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a cumprir dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar duzentos e cinquenta dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao telefone celular apreendido, é bem cuja posse, por si só, não configura fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens poderão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

P.R.I.

Bauru, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA